

Marco Legal de la Información
Clase 1
Elementos Básicos de la ciencia jurídica

El Derecho

1.1 Concepto: El concepto de derecho genera grandes controversias, según la postura iusfilosófica que se adopte. Veamos algunos ejemplos:

El derecho es la realidad compuesta por conductas humanas en relación de alteridad social¹

...conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conformes con la justicia²

...Un orden coactivo, como un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos bajo la forma de sanciones socialmente organizadas³

Cabe preguntarse, sin embargo, si estas definiciones constituyen un elemento útil para comprender un fenómeno jurídico determinado (¿cual es el derecho argentino?) o si, en cambio, constituyen un intento de aprehensión de las supuestas características comunes a todos los ordenamientos, mas allá de las particularidades de cada uno (¿Que es derecho?).

Las infinitas y muchas veces bizantinas discusiones respecto a la realidad del derecho, esconden en realidad la concepción muchas veces no expresadas respecto a que la validez del derecho deriva de una idea anterior de carácter imanente, a la que el primero debe necesariamente referir. En función de ello, la definición abstracta de derecho cobra vital importancia, atento que constituye el standard respecto del cual un conjunto organizado de normas se compara a los efectos de otorgarle o no la categoría de derecho.

En otras palabras si, por ejemplo, adoptamos la definición de Borda, podemos llegar a concluir que toda norma contraria a los derechos humanos fundamentales no constituye derecho, por ser eminentemente injusta. Dicha concepción, si bien puede ser loable desde el punto de vista moral, desconoce toda regulación sobre el comercio de esclavos, institución si se quiere aberrante, la que sin

¹ Bidart Campos, "Tratado elemental de derecho constitucional", Tomo 1, pag. 29, Ediar, Bs As, 1989

² Borda, Guillermo, "Tratado de derecho Civil - Parte general" Tomo I, pag. 12, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1987

³ Kelsen, Hans, "Teoría Pura del derecho", Pag. 71, Eudeba, Buenos Aires, 1986.

embargo, se mantuvo con variaciones por el término de mas de dos mil años, lapso visiblemente superior a la declaración derechos del hombre.

En realidad, las definiciones de derecho expuestas al comienzo del presente párrafo, constituyen los que algunos autores denominan “*definición persuasiva*”, al cual necesariamente incluye una toma de posición del estudioso frente al objeto a definir; posición que se traslada e influye en su interlocutor a través de una definición que se entiende objetiva⁴. En verdad, la mera descripción del objeto no debería impedir su calificación autónoma desde el punto de vista valorativo: Vg. El hecho que se admita el contrato de compraventa de esclavos como derecho no implica en modo alguno el apoyo a la institución.

Frente a esta realidad, la definición de un ordenamiento jurídico, se torna mucho más simple, si nos restringimos a un ordenamiento determinado, evitando los intentos generalizadores. Atento a ello, podemos definir al **ordenamiento jurídico**, como **el conjunto organizado de normas emanadas de un poder estatal competente, las cuales son percibidas por la población como obligatorias.**

Analicemos la definición por partes:

Conjunto organizado de normas: Todo ordenamiento jurídico implica necesariamente una jerarquía entre las distintas normas que lo componen, de forma que sea posible definir en forma previsible cuál es la ley aplicable a un caso concreto.. Principios como la supremacía constitucional o la de la ley penal más benigna simplemente constituyen formas de definir en el caso de leyes en conflicto cuál de ellas será la prevalente. De esta manera, los sujetos de derecho pueden saber de antemano cuales serán las consecuencias legales de sus conductas y adecuar las mismas en función de ello.

Emanadas de un poder estatal competente: Toda norma necesariamente deriva su fundamento de la existencia de un estado que la crea y esta encargado de velar por su cumplimiento. Aún en los casos en que la norma parece emanar de los particulares, es el estado que reconoce dichas convenciones y les otorga o no efectos jurídicos. En nuestro ordenamiento, dicho principio se encuentra consagrado en el art. 1197 del Cod. Civil. al sostener que las convenciones nacidas de los contratos vinculan a las partes “...*como la ley misma*”.

⁴ Al respecto, ver Ross, Alf, “Sobre el derecho y la justicia”, pag. 57 y sig., Eudeba, 1997.

El problema de la competencia, hace referencia a cuales son los organismos con potestad para ejercer esta capacidad normativa. Debe tenerse en cuenta que una norma dictada por un organismo incompetente carece de efecto, y por ende no forma parte del ordenamiento. Sobre este problema volveremos en oportunidad de analizar las formas del estado y el gobierno.

Las cuales son percibidas por la población como obligatorias:

Cualquier norma jurídica debe, por necesidad, contemplar mecanismos que permitan corregir o castigar el apartamiento de las conductas que pregonan, so pena de transformarse en una mera recomendación. En función de ello, podemos decir que la coerción forma parte necesaria de cualquier ordenamiento jurídico. Hans Kelsen⁵ sostiene que lo nota definitoria de una norma jurídica la constituye la sanción, que es consecuencia de la conducta jurídicamente disvaliosa. La misma es definida *“como un acto coactivo que consiste en la privación, forzada si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier otro valor, tenga o no contenido económico”*.

En realidad, la característica analizada guarda directa relación con el carácter estatal del ordenamiento. Entre ambas constituyen uno de los elementos esenciales de la moderna doctrina jurídica⁶: La prohibición de la justicia por mano propia o visto desde la perspectiva del estado, el monopolio de la fuerza por parte de este último. De esta forma, es el estado, quién, a los efectos de regular la conducta de los individuos, mantiene para sí la potestad de hacer cumplir las leyes por él dictadas. Desde esta óptica, el ordenamiento jurídico se presenta como un regulador de la fuerza, definiendo bajo que circunstancias y mediante que organismos, la misma es aplicada a los particulares sujetos a su esfera de soberanía.

1.2 Derecho Objetivo y Subjetivo:

1.2.1. Concepto: La palabra derecho, en realidad es usada en un doble sentido. En primer lugar, tal como analizamos en el apartado anterior, como el conjunto organizado de normas vigentes de un país. A este aspecto se lo conoce como derecho objetivo, positivo o vigente.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el derecho objetivo, tal como su nombre lo indica, mantiene un carácter general, sin especificar situaciones particulares. Por ejemplo, el art. 1113 del

⁵ Kelsen, Hans, Op. Cit., Pag. 70 y sigs.

⁶ Debe tenerse en cuenta que, en ordenamientos antiguos como el Romano, existían formas de cobro compulsivo ejecutadas por el acreedor sobre la persona del deudor.

Código Civil plantea la obligación de reparar los daños producidos por peligros derivado de las cosas, sin especificar si en el caso concreto, una persona en particular tiene o no derecho a reclamar daños y perjuicios a otra por un hecho determinado. Por tanto, existe otro aspecto de la palabra derecho que refiere a los efectos que sobre los particulares tiene el ordenamiento jurídico. A este aspecto, se lo conoce como derecho subjetivo y se lo puede definir *como la facultad legal de exigir a otra persona una determinada conducta*⁷.

Como se puede ver en realidad, ambos conceptos guardan una estrecha relación, de forma tal que el derecho subjetivo constituye a la vez la consecuencia y el aspecto dinámico del derecho objetivo: Mientras este constituye una enunciación estática de carácter general, el subjetivo es su aplicación a una situación determinada en el tiempo y en sus sujetos, permitiendo la efectiva aplicación de los presupuestos expresados en la letra fría de la ley.

Mucho se ha sostenido respecto a cuál es la naturaleza de los derechos subjetivos. Las teorías clásicas, sostienen que se trata de un reconocimiento de una voluntad por parte del derecho. Esta concepción es criticada principalmente por su carácter absoluto: Si el ejercicio de una voluntad reconocida por el derecho es válido, cualquier acto que esta voluntad realice, más allá de su carácter abusivo, constituye un acto lícito.

La primera limitación a este concepto, provino de la doctrina alemana. En el siglo XIX, uno de sus máximos exponentes, Von Ihering, sostuvo que constituía “...una *interés jurídicamente tutelado*”. A este respecto, el cambio, más allá de su diferencia semántica, permite sostener que el ejercicio de un derecho encuentra su límite en el interés que el legislador mantuvo al consagrarlo. Dicha concepción dio pie durante el siglo XX a la elaboración de la doctrina del ejercicio abusivo de un derecho o abuso de derecho como causal de responsabilidad patrimonial.

Desde un punto de vista lógico, existen voces que niegan la existencia de un derecho subjetivo. Kelsen sostiene que en realidad los sujetos no serían titulares de derechos sino simplemente de obligaciones impuestas en beneficio de un tercero. Ello obedece a que dentro de la concepción kelseniana la norma se circunscribe a marcar las obligaciones del sujeto, no a definir sus derechos. Por tanto, lo que para la doctrina tradicional es un derecho, para el autor austríaco es el cumplimiento de un deber por parte del obligado.

Más allá de la discusión filosófica, el instituto del derecho subjetivo cumple numerosas funciones dentro del ordenamiento. La principal es la idea de una titularidad de derecho, que constituye una

parte fundamental del derecho procesal, al definir quien puede reclamar la ejecución forzada de un derecho, concepto conocido como legitimación activa.

1.2.2. El derecho objetivo: Sus divisiones: Si bien el ordenamiento constituye un único sistema, a los efectos de su estudio, la ciencia jurídica lo ha dividido en diferentes ramas, cada una de las cuales mantiene una autonomía científica respecto de las demás.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que estas divisiones son básicamente arbitrarias y en muchas ocasiones la solución de los problemas jurídicos involucran dos o más ramas al mismo tiempo

Los principales criterios clasificatorios son:

A.- Derecho de forma y fondo o sustancial: Esta clasificación divide las normas jurídicas en función de si las mismas definen derechos o relaciones jurídicas entre las partes o si por el contrario, constituyen reglas destinadas a conducir los procedimientos ante la autoridad competente en caso que estos derechos se encuentren en disputa. En el primer caso nos encontramos frente a una norma de fondo o sustancial y en el segundo, frente a una norma de procedimiento o de forma.

Esta diferenciación reviste particular importancia en nuestro país atento la facultad delegada de las provincias en la nación de legislar la legislación de fondo.

B.- Derecho Público y Derecho Privado: ha existido durante largo tiempo una discusión respecto a cuál es el concepto preciso del derecho público. En principio, se lo definió como aquel donde la relación entre las partes no es horizontal o entre dos iguales sino que existe un componente de subordinación del individuo respecto del estado. El problema de esta definición radica en el hecho que no toma en cuenta al derecho internacional público, cuyas relaciones se establecen entre estados soberanos, circunstancia que elimina todo tipo de subordinación.

En realidad, la sola presencia del estado en una relación jurídica no permite afirmar que estamos frente a una figura del derecho público, es necesario que el mismo se encuentre cumpliendo su función de poder público, entendiendo el mismo como aquellas actividades esenciales para el desenvolvimiento social (vg justicia, seguridad, educación), en contraposición con el accionar del estado como persona de derecho privado (en los casos en que el estado realice contratos civiles como alquileres o compraventa de insumos).

Entre las ramas del derecho público se encuentran:

El Derecho Constitucional: Podemos hablar del derecho constitucional en un doble criterio⁸: Con un criterio formal, es el estudio del texto constitucional. En un sentido material, el constitucionalismo constituye el análisis de la estructura del poder del estado, entendiendo el mismo como el mecanismo que limita y define la toma de decisiones del estado, ya sea que el mismo este contenido en texto constitucional o se encuentre fuera del mismo. De esta forma cuando hablamos de constitucionalismo en el sentido material no solo nos interesará el texto que consagra, verbigracia, la libertad de prensa, sino que, asimismo, es de vital importancia entender cual es la postura que al respecto han mantenido los tribunales.

El Derecho Penal: Establece y regula el poder punitivo del estado respecto a conductas previamente calificadas como delitos.

El Derecho Internacional Público: Rige las relaciones entre los estados como poder público.

El Derecho Administrativo: Regula el funcionamiento de la administración pública y las relaciones entre la misma y los particulares.

El derecho privado, en su concepción más clásica, carece de la nota de orden público que caracteriza a su contraparte. Las relaciones se establecen entre partes en pie de igualdad y los bienes jurídicos protegidos revisten un carácter más económico que social.

En la actualidad, los conceptos antedichos están puestos en tela de juicio, produciendo la introducción de elementos del derecho público en las relaciones económicas. Fenómenos como el constitucionalismo social, la economía de masas o los movimientos sociales de principios del siglo XX, llevaron a limitar el concepto de propiedad así como el axioma de la igualdad de las partes al contratar. Atento ello, el derecho interviene a los efectos de equilibrar la relación contratar de forma tal de evitar los abusos que la posición dominante de una parte pueda tener sobre la otra.

Entre las ramas del derecho privado, podemos mencionar:

El derecho civil: En realidad, el derecho civil es la más antigua de las ramas del derecho. En el derecho romano, el derecho civil (*ius civile*) se refería a todo el orden jurídico que se aplicaba a los ciudadanos, en contraposición al *ius gentium*, que denominaba al derecho que se aplicable al resto de los habitantes del imperio. Dicho derecho contaba con normas tanto de derecho público como

⁸ Bidart Campos, Op cit, pag. 35 y sig.

de derecho privado, circunstancia que lo diferencia de manera clara de su concepción moderna.

Son los glosadores medievales los que dan forma al derecho civil tal como lo conocemos, al recuperar la legislación romana y eliminar las regulaciones referentes al poder estatal, las cuales ya carecían de sentido, atento el hecho que el imperio había desaparecido casi mil años antes.

En razón de ello, el derecho civil constituye la rama más antigua y de la cual las distintas ramas se derivan. Precisamente por esta circunstancia histórica, el derecho civil es muchas veces conceptuado como un derecho por sustracción, un cúmulo amorfo de normas y principios que restan una vez separado las relaciones jurídicas regidas por las otras ramas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el derecho civil en su concepción actual mantiene un objeto de estudio que son las relaciones jurídicas que se establecen frente los sujetos de derecho en su condición de tales y con independencia de la actividad que desarrollen. Así por ejemplo, las relaciones familia, las relaciones de propiedad, los actos jurídicos y los mismo derechos derivados de la condición de persona jurídica (derechos personalísimos), constituyen objeto de estudio de esta rama del derecho.

El derecho comercial: Regla la estructura de la empresa, las relaciones de los comerciante y las consecuencias jurídicas de los actos de comercio que se realizan.

El derecho laboral: Norma las relaciones derivadas del contrato de trabajo, ya sea a nivel individual como en los casos de negociación colectiva. En realidad, la ubicación del derecho laboral dentro de la órbita del derecho privado obedece a cuestiones históricas derivadas del desprendimiento del derecho civil. Sin embargo una de sus notas definitorias esta dada por el denominado orden público laboral, es decir la limitación del poder de disposición de los particulares en la negociación de los términos del contrato. Esta característica, sumada a la intervención activa del estado en la negociación y control del contrato de trabajo, hace que esta rama del derecho presente elementos de ambas clasificaciones, lo que lo torna en un figura mixta.

Las fuentes del derecho:

1.- Concepto: La expresión fuentes del derecho es utilizada a los efectos de denominar conceptos diferentes. En un sentido filosófico, refiere a los antecedentes ideológicos tenidos en cuenta a los efectos de la redacción de la ley. Este es el sentido que se le da en el preambulo de la constitución cuando invoca a dios “...*fuentes de toda razón y justicia*”.

En similar sentido pero desde el punto de vista histórico, las fuentes del derecho constituyen los antecedentes legales, sociales o políticos que dan lugar a la creación de una norma. Siguiendo con el ejemplo anterior, los pactos preexistentes entre las provincias o los antecedentes constitucionales de los EE. UU. constituyen las fuentes históricas de la Constitución Nacional.

En un último sentido, y este es el que nos interesa desde el punto de vista jurídico, las fuentes del derecho denotan los fenómenos jurídicos que originan derechos y obligaciones en los diferentes sujetos del ordenamiento.

2.- La Ley:

2.1- Concepto: En un sistema continental o romanista de derecho, como el nuestro, la ley la fuente fundamental y primera del derecho: Su preponderancia en es clara respecto al resto de la fuentes, las cuales muchas veces constituyen fuentes solo en los casos en la ley la recepciona expresamente.

Podemos hablar de la ley en un doble sentido, material y formal. Formalmente, se llama ley a toda norma emanada del Poder Legislativo de acuerdo con el procedimiento contemplado en la constitución. Desde un punto de vista material, la ley es toda norma emanada por una autoridad competente. Por consiguiente, en este sentido no solo son leyes las emitidas por el poder ejecutivo, sino también la emanadas por el poder ejecutivo mediante decretos y resoluciones, la constitución los edictos policiales , etc.

Si bien a primera vista la concepción formal aparece como un concepto más restringido que el material, en realidad, es al mismo tiempo más amplio, incluyendo actos del congreso que no constituyen leyes desde el punto de vista material. En este sentido, las leyes emanadas del congreso que realizan declaraciones u otorgan algún tipo de beneficio a personas o personas determinadas, no cumplen con los requisitos de generalidad o de prescripción de conductas obligatorias, circunstancias que no permiten considerarlos leyes en el sentido material.

2.2. Clasificación de las leyes: Tal como vimos con las ramas del derecho objetivo existen diferentes criterios clasificatorios respecto de las leyes

1.- Respecto a su contenido: Tal como analizamos respecto a la ley en sentido formal, no toda norma emanada del órgano legislativo contiene una prescripción de carácter general. Merced a ello, podemos dividir las leyes en:

a.- Autónomas o completas: El contenido lógico se encuentra condensado en una sola preposición lógica. De esta forma la norma legal se basta a si misma a los efectos de definir la cuestión objeto de la misma.

b.- No autónomas o incompletas: Son aquellas normas que no cumplen con los requisitos de las normas autonomas. Entre estas podemos encontrar:

Definiciones legales: Son aquellas normas que no contienen preceptos de conducta, sino simplemente definen uno o varios concepto jurídicos. Ejemplo: La definición de firma electrónica de la ley de Firma digital

Explicativas: Contienen una explicación sobre el alcance de un término utilizado en una tercera norma. Ej. La norma que marca que los plazos de un código de procedimiento se cuentan por días hábiles y no corridos.

Modificadoras o limitativas: Son las que establecen un limite o modificación a otras normas. Ej el art. 14 del Código Civil respecto a la aplicación de la ley extranjera.

2.- Por su estructura: Las leyes pueden ser flexibles o rígidas.

Rígidas: Son aquellas cuya disposición es precisa y concreta, de forma que el su aplicación se limita a la comprobación de los presupuestos de hechos contemplados en su enunciado y su consecuencia es única y claramente fijada por la ley. Ej: *La mayoría de edad se cumple a los 21 años.*

Las Flexibles en cambio, permiten al juez una mayor libertad al momento de la interpretación e integración de la norma. Así por ejemplo el art. 953 del Cod. Civil declara nulas las normas que se oponen a las buenas costumbres. En un mismo sentido, el código civil abunda en términos como *“buen padre de familia”*, *“deber de obrar con prudencia”*, *“caso fortuito o fuerza mayor”*, todas ellas fórmulas elásticas que involucran una influencia determinante de la opinión social, las convicciones religiosas y la propia formación del operador jurídico.

Por el nivel de validez en relación a la voluntad de las personas: Las leyes pueden ser imperativas o supletorias.

Son imperativas aquellas normas que prevalecen sobre la voluntad de las partes, de forma tal que las convenciones entre las partes formuladas en contraposición de las mismas se encuentran teñidas de nulidad. Las mismas pueden estar expresadas en forma de prohibiciones o con un criterio afirmativo pero en ambos casos el efecto es el mismo: Los particulares no pueden apartarse de lo prescrito so pena de tenerse por no escrito lo pactado.

Las leyes supletorias, en cambio, son aquellas que las partes pueden dejar de lado de común acuerdo. Estas normas son comunes en materia constitucional. El objeto de las mismas es suplir las omisiones que las partes hayan realizado en el momento del contrato. Sin embargo, si las partes no encuentran la solución legal de su agrado pueden apartarse de la misma, mediante una cláusula en sentido contrario.

La importancia de la presente clasificación radica en el hecho que en la práctica regula la libertad de las partes al contratar. En este sentido, las normas supletorias han disminuido en los últimos años, merced a la crisis en el concepto de igualdad negocial en los contratos de adhesión y la economía de masas.

3.- La costumbre:

Concepto: Para que exista costumbre, en el sentido otorgado por la ciencia jurídica, deben reunirse dos elementos básicos. Uno material, la repetición de conductas de manera constante y uniforme en una sociedad y el segundo, de carácter subjetivo, como es la percepción de dicha conducta como obligatoria, lo que elimina a los llamados usos o costumbres sociales.

La importancia de la costumbre como fuente de derecho ha variado en función del paso del tiempo. Si bien en un principio, en los ordenamientos más primitivos, constituyó la fuente principal de normas, la evolución social fue dejándola de lado en pos de una formulación escrita de los preceptos sociales. Sin embargo, a partir del siglo XX, la costumbre es nuevamente revalorizada en función de los criterios realistas de interpretación jurídica, lo que da lugar a la recepción en nuestro derecho de dicha fuente.

El código civil argentino regula la costumbre en el art. 17. En su concepción original, la costumbre sólo podía ser fuente en los casos en que la ley la receptara expresamente careciendo de efectos en los casos que se opusiera a esta última o incluso cuando normara cuestiones omitidas por la ley.

Esta solución, si bien se encuentra en concordancia con los principios racionalistas imperantes en la época, no se condice con la realidad social que ya en ese momento existía. Cuestiones como el nombre de las personas y el régimen legal de los sepulcros carecían de regulación legal y se regieron por la costumbre hasta casi sesenta

años después de aprobado el código, lo que tornaba la solución legal en inadecuada.

En 1968, la reforma del código civil realizada por el decreto ley 17711 otorgó fuerza legal a la costumbre en los casos de silencio de la ley. Sin embargo, sigue prohibiendo la costumbre en los casos en que la misma se opone a al texto expreso de la ley.

4.- La jurisprudencia:

4.1 Concepto: El termino se refiere a los fallos de los tribunales judiciales que sirven de precedentes a futuros pronunciamientos⁹.

Para que haya jurisprudencia no es necesario que los precedentes se extiendan en el tiempo, en muchas ocasiones la existencia de un solo pronunciamiento al respecto sienta jurisprudencia: En tales casos se dice que estamos en presencia de un *Leading Case*.

4.2 Su importancia: Sin bien las normas creadas por los jueces son obligatorias, su alcance se limita a las partes intervinientes en el pleito judicial, no siendo oponibles a terceros. En función de ello, cabe preguntarse cómo la jurisprudencia puede tener efectos más allá de los involucrados directos.

En primer lugar la interpretación de una norma judicial no es única: Es el poder judicial quien, en última instancia, delimita el alcance de un texto, terminando cuales de las interpretaciones del enunciado de la ley es el aplicable al fallar en el caso concreto. Atento ello, algunos ius filósofos de la escuela realista americana sostuvieron que *la ley es lo que el juez dice que es*¹⁰.

En segundo lugar esta interpretación no es una constante, sino que varía en función de los cambios tanto en la ciencia jurídica como en la realidad social sobre la cual operan los jueces. La interpretación de la ley por parte de estos, deja entonces de ser un mero ejercicio mecánico y se transforma en una forma de autentica creación jurídica: opera sobre el mismo texto literal pero se aparta de las soluciones hasta ese entonces, creando de hecho una nueva norma jurídica.

Por último, debe tenerse en cuenta que la ley no establece principios de carácter general, de forma tal que solamente se pueden prever un número limitado de casos fácticos de un universo mucho más grande. De esta manera, se produce lo que en derecho se conoce como el fenómeno de las lagunas del derecho: en muchas casos el texto legal nada dice, y es entonces cuando el juez,

⁹ Borda, op cit, pag. 81 sig

¹⁰ Entre ellos podemos citar a Wendell Homes y Hughes, ambos jueces de la suprema corte de Estados Unidos de Norte América.

quien por ley esta obligado a fallar, integra la norma, creando una solución al problema no contemplado legalmente. Su pronunciamiento será entonces creador de derechos y obligaciones no solo para las partes sino también servirá como guía a los demás sujetos del ordenamiento jurídico, quienes pueden prever cuál será el fallo en un caso concreto.

Efectos de la ley con relación al tiempo:

1.- Concepto:

El problema de los efectos de la ley con relación al tiempo involucra dos cuestiones fundamentales a dilucidar: La primera, cuándo una ley comienza a ser obligatoria para los sujetos de derecho. La segunda, si existe la posibilidad de otorgar efectos retroactivos a la ley y en dicho caso, cuales son los límites a dicha actividad.

2.- Fecha de entrada en vigencia:

El art. 2 del código civil determina la obligatoriedad de las leyes a partir de su publicación. El plazo puede variar siendo potestad del legislador fijar un plazo mayor o menor según su conveniencia. Si nada dice, el código civil establece un plazo supletorio de ocho días a contar desde el día siguiente a la publicación en el boletín oficial. Por ejemplo una ley publicada en el boletín oficial el 11 de abril tendrá vigencia recién el 20 de abril inclusive.

El término ley se utiliza en este art. como ley en sentido material, de forma tal que los decretos del poder ejecutivo y las ordenanzas municipales también deben ser publicados. A partir de la ley 16.504 del año 1964 esta publicación sólo es válida si se realiza en el boletín oficial, publicación del estado de carácter diario que recoge las leyes y decretos. Las ordenanzas municipales en cambio son publicitadas en el Boletín Municipal.

Como se puede ver la publicación de una norma reviste singular importancia atento el hecho que a partir de la misma se comienza a contar los plazos para su obligatoriedad. Para la doctrina tradicional esto obedece a que solo a partir de este momento la ley es conocida por la población, premisa que en la realidad, esta lejos de cumplirse: el boletín oficial es leído por pocas personas, por lo que resulta imposible considerar al mismo como un mecanismo efectivo de publicidad. Sin embargo, la necesidad de previsión en las relaciones jurídicas mantiene la ficción jurídica del conocimiento de la ley, más allá de la capacidad de conocimiento real que pueda tenerse.

3.- Aplicación retroactiva de la ley:

Por regla general las relaciones jurídicas no se culminan en un solo instante sino que tienden a mantenerse en el tiempo, de forma tal que la entrada en vigencia de una ley puede modificar los efectos que estas venían teniendo hasta ese momento. Para que estemos frente a una ley retroactiva esta modificación debe darse

respecto a efectos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva norma. Por ejemplo, una ley que ordena un aumento de la tasa de interés de un préstamo sería retroactiva en el caso que obligara a los deudores a abonar la diferencia desde el comienzo de la deuda. Si en cambio, simplemente ordenara el aumento para las cuotas que restan, no estaríamos frente a efectos retroactivos sino inmediatos.

El problema de la aplicación retroactiva de la ley fue asociado en la reglamentación original del código civil con el principio de protección de la propiedad privada. De esta manera, el art. 3 de dicho ordenamiento prohibía el efecto retroactivo, en tanto afectara derechos adquiridos.

El problema fundamental de dicha formula que es toda cambio legislativo, en forma mediata o inmediata, implica un avasallamiento de derecho adquirido. A mayor abundamiento, tanto la ley como la jurisprudencia carecían de una determinación precisa del concepto de derecho adquirido, lo que dificultaba sensiblemente la aplicación de la norma. Atento a ello, la ley 17.711 modificó el texto del art. 3 por el siguiente:

A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley, en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

A los contrato en curso de ejecución, no son aplicables las nuevas leyes supletorias.

Analizando el texto de la ley vemos que hay dos hipótesis fundamentales, aludidas en el mismo:

La primera es lo que el texto llama situaciones jurídicas generales, es decir, los derechos regidos por la ley y no por la voluntad de las partes. Como ejemplo podemos citar los derechos reales o las relaciones de familia. En estos casos la ley se aplica desde su entrada en vigencia.

Respecto a las relaciones regidas por la voluntad de las partes debemos diferenciar según el tipo de norma. En el caso de normas imperativas, su aplicación comienza desde su entrada en vigencia. En cambio el caso de normas supletorias, la modificación no tiene efectos respecto a contratos ya iniciados.

El fundamento de esta solución legal es que, como ya vimos, la norma supletoria integra el contrato cuando las partes no dispusieron nada en contrario. Merced a ello, el acuerdo de voluntades se compone por lo que las partes expresamente acordaron con más lo que la ley marca en caso de silencio. La aplicación de una nueva norma en este caso implica una modificación de la voluntad de las partes al contratar, quienes

pudieron haber guardado silencio simplemente por estar de acuerdo con la solución legal al caso. Distinto es el caso de las normas imperativas, atento que, en dicho caso, la ley no permite a las partes apartarse de lo prescrito legalmente y, por ende, la solución debe guarda analogía con lo normado para la primera hipótesis.

Asimismo, el texto de la ley limita el alcance de la retroactividad de la ley a los casos en que no se haya afectado un derecho constitucional. A este respecto es importante señalar que se elimina la referencia al derecho de propiedad y/o los derechos adquiridos que han generado una fuerte controversia jurisprudencial a favor de una mayor precisión doctrinaria. Sin embargo, en función del principio de supremacía constitucional, debe admitirse que en realidad, ninguna ley, retroactiva o no, puede afectar un derecho constitucional.

Ello no significa que los derechos constitucionales son absolutos. La Corte Suprema ha sostenido en repetidas ocasiones¹¹ que todo derecho es susceptible de regulación, mientras que la misma no desnaturalice su esencia o los torne una mera declaración sin efecto jurídico. En función de ello ha aceptado en repetidas ocasiones la constitucionalidad de las llamadas leyes de emergencia, cuestión cuyo análisis excede con creces los objetivos de este trabajo.

¹¹

Al respecto ver los casos Cine Callao, Peralta o Smith.

Elementos de las relaciones jurídicas

1.- Los sujetos: Toda relación jurídica implica necesariamente la existencia de sujetos de derecho, ya sea de existencia física o legal (sociedades, fundaciones, cooperativas o demás casos en que la ley otorga capacidad para ser titular de derechos y obligaciones). Respecto a una relación jurídica determinada podemos clasificar a los sujetos en:

La Partes: Las partes de una relación jurídica son aquellas que por sí o por intermedio de un representante, se han obligado a cumplir cierta conducta o son titulares de un determinado derecho. Debe tenerse en cuenta que, en los casos de actos jurídicos, debe diferenciarse entre las partes y los firmantes u otorgantes del acto: Si bien en la mayoría de los casos ambas figuras coinciden en la misma persona, no necesariamente esto es así, como lo demuestra la figura del mandatario o representante ya sea legal o convencional.

Asimismo se considera partes a los sucesores universales de una persona fallecida. Esto es así porque para nuestro ordenamiento los sucesores de una persona fallecida continúan el lugar jurídico del causante. Sin embargo esta regla tiene excepciones:

1.- En los casos en que la obligación se hubiera realizado teniendo en cuenta las características personales del fallecido. Tal es el caso de la mayoría de las locaciones de obra, particular cuando el encargado de la obra contaba con cualidades particulares que eran definitorias del contrato (ej. El encargo de una obra a un pintor)

2.- En los casos que las partes al momento de contratar hayan definido que al muerte de una de ellas resuelve el contrato. En tal caso, los sucesores, si bien continúan la persona del causante, no están obligados a prestación alguna ya que la misma dejó de existir con el fallecimiento.

3.- Los casos que se acepte la sucesión con el llamado beneficio de inventario. En tal caso los patrimonios del sucesores y el causante no se mezclan y se evita la confusión entre los mismos.

Los terceros: Desde un concepto amplio, puede decirse que un tercero es todo aquel que no es parte de una relación jurídica. Como principio general, los actos realizados por las partes no tienen efectos contra los terceros, salvo en el caso de transmisión de derechos reales, los cuales son oponibles contra cualquier persona, haya o no participado en el acto de cuestión.

2.- La Causa:

La palabra causa tiene en el derecho dos acepciones diferentes: La primera refiere al hecho respecto del cual derivan las obligaciones, ya sean estas un hecho ilícito, la voluntad de las partes o simplemente la misma ley.

La segunda, y es la que nos interesa a los efectos de este apunte, significa el fin que las partes se propusieron al contratar. Según la doctrina más difundida, la causa es el fin inmediato y determinante que las partes han tenido al contratar, es la razón directa y concreta que las partes para la celebración del acto y atento ello, no puede ser ignorada por la contraparte.

Debe igualmente diferenciarse la causa de los meros motivos que las partes tuvieron al contratar. La primera son los fines inmediatos que una persona tuvo al celebrar un acto, la segunda, en cambio, son las motivaciones psicológicas que llevaron a las partes a hacerlo, las cuales no tienen efectos jurídicos inmediatos. Así, por ejemplo, en un contrato de compraventa de inmuebles, la causa es para el vendedor es el pago del precio, en cambio si los motivos puede ser la compra de un inmueble mas grande. Para el derecho, la satisfacción de este motivo ulterior carece de efectos: compre o no el segundo inmueble, la operación es válida.

La principal regulación de la causa, esta dada por los art. 500 y 502 del código civil. Ellos regulan los problemas derivados de la nulidad, o falsedad de la causa y sus efectos jurídicos. El art. 500 establece una presunción de existencia de la causa, aun en los casos en que la misma no este expresada al momento de la obligación. Esto obedece al hecho que por razones de seguridad jurídicas la validez de los negocios jurídicos se presume, siendo carga de quien plantea su nulidad la prueba de dichos extremos.

Sin embargo, puede ser la causa no existe, sea contraria a derecho o existiendo la misma sea falsa. En los dos primeros casos nos encontramos con una relación jurídica sin causa, la cual debe reputarse nula (art. 502). Sin embargo, en el último caso, vemos que si bien la causa manifestada es falsa, puede ocultar otra válida. Tal es el caso de los actos simulados, donde las partes conscientemente crean una causa falsa, normalmente en perjuicio de sus acreedores u otro tercero, para ocultar otra causa real. En tales casos, el ordenamiento sostiene que si la causa real es válida, el acto simulado se mantiene. Esto es de particular importancia respecto a los terceros, toda vez que pueden oponer el acto a los simuladores, si así les conviene.

3.- El Objeto: El concepto de objeto refiere a la cosa o hechos sobre la cual recae la obligación contraída. En otros términos se trata de la prestación debida.

El objeto constituye un elemento fundamental de la relación jurídica, toda vez que no puede entenderse una relación obligacional donde nadie tenga obligación de nada. Sin embargo, no todo objeto es válido, debiendo cumplir lo normado por el art. 953 del Código Civil, el cual expresa:

El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de un acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conforme a esta disposición son nulos como si no tuviesen objeto.

En función del texto del artículo, vemos que el objeto debe cumplir con tres condiciones básicas:

1.- Debe ser Posible: Esta posibilidad física de realizar la prestación debe ser absoluta y no relativa al contratante. Por ejemplo, la obligación de construir una catedral o pintar un retrato puede resultar imposible para una persona no entrenada, pero la obligación sigue siendo válida entre las partes y su incumplimiento conlleva sanciones. En cambio, la prestación “saltar un edificio” es físicamente imposible y debe reputarse nula.

2.- Debe ser lícito: Todo objeto contrario al ordenamiento es nulo. Ello obedece a que el ordenamiento no puede otorgar validez a un acto que niega su vigencia, so pena de caer en un contrasentido lógico.

3.- Debe ser conforme a la moral y las buenas costumbres: Este concepto constituye un standard jurídico, el cual debe evaluarse en el caso concreto. Sin embargo, es conteste la jurisprudencia en calificar estas actividades como contrarias a la moral: La locación de inmuebles para casas de citas, los pactos de retroventa de automotores como garantía de un préstamo¹², los intereses usuarios.

Respecto a los efectos debe tenerse en cuenta si la prestación constituye una parte esencial de la convención o si, por ejemplo en los casos de pactos de retroventa o intereses, estamos frente a un accesorio. Normalmente en el primer caso se decreta la nulidad de toda la convención, mientras que en el segundo, simplemente afecta a la cláusula, dejando la relación jurídica

¹² Es particularmente común, en los casos de préstamos usurarios, la venta al prestamista de un automotor o inmueble como garantía con el agregado de una cláusula de devolución al deudor en caso de cumplimiento y de esta forma evitar la ejecución de la deuda o su discusión judicial. Esta convención accesorio es conocido como pacto de retroventa